

THÈME 1 : LE CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION PAR LE JUGE JUDICIAIRE

Section 1 – Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et la dualité des ordres juridictionnels

1) Le principe de séparation

En France, le droit admin est un droit autonome distinct du droit commun avec une juridiction (le CE) à la tête d'une organisation juridictionnelle. Est à la tête de deux activités :

- activité de SP
- activité de prescription (PA)

Il y a trois pouvoirs dont l'un est le pouvoir exécutif dont dérive le pouvoir de l'admin. Ce pouvoir doit être totalement distinct du pouvoir judiciaire.

Après la révolution, il est interdit au juge judiciaire d'entraver l'action de l'administration, mais l'admin ne peut pas être hors de tout contrôle.

L'admin devient donc son propre juge :

→ théorie du ministre juge = le ministre peut être amené à contrôler l'admin

Mais : insécurité juridique (pas de garanti pour l'administré que son affaire soit traitée de manière totalement indépendante, totalement libre du fonctionnement de l'admin)

2) La dualité des ordres juridictionnels

2 ordres de juridiction :

- le judiciaire
- l'admin (né d'une lente évolution qui débute avec la création du CE)

Lorsque le JA est compétent, le JJ ne peut pas l'être car les questions de repartitions des compétences sont des **q° d'ordre public**.

→ Les règles doivent être respectées à tout moment de la procédure et peuvent être invoquées à tout moment de l'instance (CE, 4 octobre 1967, Trani)

► la naissance difficile de la dualité des ordres juridictionnels

À l'origine, le CE n'est pas une juridiction (théorie du ministre juge) mais est chargé de rédiger les projets de loi...[et] de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative (**Article 52 de la Constitution du 22 Frimaire an VIII**).

- À partir de 1806 : **le CE se voit remettre les premières compétences juridictionnelles**, mais les décisions du CE ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée.

- **loi du 24 mai 1872** : les décisions du CE ne sont plus soumises au pvr exécutif

- TC 1873 Blanco : la responsabilité qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie ne peut être régie par les pp établies dans le code civil. Cette responsabilité a ces règles spéciales et l'autorité administrative est seule compétente pour en connaître.

Le droit admin est bien un droit spécial qui est exorbitant du droit commun

- **CE, 13 décembre 1889, Sieur Cadot** : les litiges entre une admin et un particulier sont de sa compétence (JA compétent).

Le juge admin est donc compétent pour connaître des litiges et applique les règles spécifiques à ce litige.

► Les garanties du respect de la dualité des ordres juridictionnels

a) L'indépendance des juridictions administratives et judiciaires

art 64 de la C^o : le Président de la République est garant de la Constit, 22 juillet 1980 : affirmer (ne parle pas de la J^oA)

C. Constit, 22 juillet 1980 : affirme l'indépendance des autorités juridictionnelles à l'égard du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif (PFRLR)

! la séparation des autorités admin et judiciaire a valeur législative

b) les question préjudicielles entre les juridictions des deux ordres

Il peut arriver que la résolution d'une litige relève des deux ordres (décision de JA et de JJ nécessaire pour régler le différent).

Situation 1 : JA saisi au principal

→ le JA ne pose aucune q^o préjudicielle au JJ. Il interprète et éventuellement écarte les règles de droit privée.

Situation 2 : JP saisi au principal

→ Le JP dispose de la plénitude de juridiction et donc le code pénal (art 111-5) l'autorise à apprécier les actes admin réglementaires ou individuels à la condition que de cet examen dépend la légalité du procès pénal.

Situation 3 : JJ saisi au principal

→ il ne peut pas apprécier la légalité d'un acte admin (mais peut l'interpréter). Il doit poser une q^o préjudicielle à la J^oA.

! TC 2011 : des lors que la difficulté d'interprétation est une question d'application du droit de l'UE, le juge judiciaire peut lui même poser une q^o préjudicielle à la CJUE

c) Le contrôle opéré par le Tribunal des conflits

tribunal spécial composé de membres du CE et de la Cour de cass.

Le TC résout les conflits de compétence :

Situation 1 : le JJ se déclare compétent dans une affaire qui relève de la compétence du JA

→ le TC décide quel ordre de J^o est compétente pour statuer sur l'affaire en cause

Situation 2 : Le justiciable se trouve face à des ordre de juridiction qui lui ont dit qu'aucun des deux n'était compétent (dénî de justice)

→ la seconde juridiction qui allait se déclarer incompétente doit saisir le TC

Situation 3 : le justiciable se retrouve avec une décisions qui a été rendu et pour laquel aucune juridiction n'est compétente.

→ C'est au justiciable de saisir le TC

Section 2 : Les attributions constitutionnelles de compétences au juge judiciaire

► La protection des libertés individuelles et de la propriété privée immobilière

art 66 de la C = L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi (JJ compétent)

CC 1977 Fouille des véhicules : la liberté individuelle relève de la seule compétence du JJ et dans cette décision que la vie privée était une liberté individuelle.

→ le champ des libertés individuelles s'est élargie mais bcp sont devenu aujourd'hui des libertés personnelles qui ne constituent pas un champ de compétence exclusif du JJ.

Il resta **la privation de liberté** qui est la liberté individuelle par nature (Nul ne peut être arbitrairement détenu al 1)

Décision TGV nord : La propriété privée immobilière relève de la compétence exclusive du JJ

→ Il existe des procédures admin qui impliquent pour être mené à terme la saisine de la juridiction judiciaire.

ex : expropriation pour cause d'utilité publique avec une phase admin ou l'A déterminé l'utilité publique du projet. Puis phase judiciaire qui autorise l'atteinte à la propriété prv immobilière

► La mise en œuvre de la protection par le jeu de la voie de fait et de l'emprise irrégulière

Cas où l'A porte atteinte à la prop prv immo ou à certaines libertés individuelles. Il est alors possible de saisir le JJ pour mettre fin à l'atteinte causée par l'admin.

TC 2013 Panizzon vs commune de Saint-Palais-sur-Mer : le juge judiciaire n'est désormais compétent qu'en cas d'extinction du droit de propriété privé immobilier.

La voie de fait : l'admin agit alors que manifestement l'opération ne se rattache à aucune de ses pouvoirs.
→ le JJ se trouvait compétent pour juger de l'opération faite par l'administration.

loi de 2000 sur les référés admin : le référé liberté permet au juge de prendre toutes les mesures demandées susceptible de mettre fin à une atteinte grave et immédiate aux libertés fondamentales.

→ pour protéger les libertés fonda l'administré disposait alors de 2 types d'actions : le référé liberté et la voie de fait par le jeu du référé civil.

TC 2013 « Bergoend » : restreint la voie de fait uniquement à l'atteinte aux libertés individuelles. Pour toutes les autres atteintes moindre que l'extinction du droit de propriété il n'y a plus de voie de fait, il faut aller devant le juge admin.

THÈME 2 : Les juridictions administratives

Section 1 : Les juridictions de droit commun et d'exception

loi du 31 décembre 1987 : existence d'un système complet de juridiction dans l'ordre administratif (uniquement le CE à l'époque)

→ apparition des juridictions du fond (TA et CA) par démembrement des compétences du CE

1) Le Conseil d'État :

► Son organisation

Siège à Paris et dispose de compétences :

- administratives (et législative dans la mesure où il participe à l'élaboration de certaines lois)
- juridictionnelles

Ses membres ne sont pas des magistrats mais sont des juges dans leur fonction contentieuse.

Il est présidé par le PM qui ne siège qu'une fois par an.

Depuis 2015 : **Formation Spécialisée du CE** (compétence très restreinte en matière des données de renseignement par la mise en oeuvre des techniques de renseignement, et en particulier les techniques visant à assurer la sécurité de l'Etat).

Est divisé en section. L'activité juridictionnelle est effectuée au sein de la section contentieuse qui est elle-même divisée en 10 chambres (chacune avec un président assisté de 3 présidents adjoints).

Les décisions juridictionnelles sont rendues par des formations différentes selon l'importance de l'affaire (4 degrés d'importance pour 4 formations de jugement différentes) :

- le plus bas : la Chambre
- si l'affaire intéresse deux chambres : Formation de chambres réunies (2 max)
- la Section du Contentieux : traite des principaux dossiers jugés par le CE (composé du Président de la section elle-même, des 3 présidents adjoints, des 10 présidents de Chambre et des membres de celle qui a instruit le dossier).
- la plus solennelle, siège très peu car juge les affaires les plus importantes de l'année : l'Assemblée du Contentieux.

⚠ Si les membres du CE ne sont pas des magistrats, la loi du 20 avril 2016 a défini des règles de déontologie ainsi que des droits et obligations pour les membres du CE pour éviter les risques de prise

► Ses compétences

a) le CE, juge de première instance

Le CE a conservé quelques compétences en premier et dernier ressort.

→ est aussi juge du fond et pas seulement, le juge de cassation des juridictions administratives.

Deux grandes catégories de demande devant le juge admin :

- **demandes d'annulation** (le contentieux de l'annulation est principalement le contentieux de l'excès de pouvoir de l'admin → le juge admin annule (totalement) la décision qu'elle a prise (la décision est réputée n'être jamais intervenue). Le CE est toujours juge de l'excès de pouvoir
- **demandes de réparation**

Les compétences du CE sont énoncées dans l'article R311-1 du code de justice admin (CJA)

Le CE juge de plein contentieux = le contentieux de la responsabilité, mais également le contentieux de l'annulation qui ne relève pas du contentieux de l'excès de pouvoir.

Le CE est aussi juge des actions en responsabilité dirigé contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative.

Le CE est **juge électoral** en matière d'élection au Parlement Européen, aux conseils régionaux, élections locales dans certaines collectivités particulières.

b) Le CE : juge d'appel

N'est plus vraiment juge d'appel depuis la création de la CA d'Appel.

Il reste juge d'appel pour :

- renvoi des juridictions judiciaires
- appel des jugements rendus pour les élections municipales et départementales
- juge d'appel des ordonnances rendues par le juge des référés du TA en matière seulement de référé liberté

c) Le CE : juge de cassation

Article L311-1 du CJA : le CE est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation. C'est auj son activité principale.

2) Les Tribunaux administratifs et les Cours administratives d'appel

► Les tribunaux administratifs

Ne sont pas très nombreux (42) et sont chacun composé d'au moins 2 chambres de 3 Conseillers. chacun. Lorsque le TA est composé de plus de 2 chambres les affaires importantes peuvent être jugées par une formation de chambre réunies (la formation plénière, réunie à titre exceptionnel pour les affaires les plus importantes).

Le TA est le **juge de droit commun**, il connaît des actes admin unilatéraux et contrats dans le cadre de son ressort géographique.

Les jugements qu'ils rendent sont susceptibles d'appel, essentiellement devant la CAA.

⚠ Dans certains cas limités, le TA est juge en premier et dernier ressort (litiges mineurs)

► Les cours admin d'appel

Sont au nombre de 9 et ses membres sont des magistrats admin. Chaque cours est divisée en Chambre (la Chambre est la formation de jugement de base, mais il existe aussi pour les affaires plus importantes la formation de chambre réunie, et la formation plénière).

Elles peuvent aussi être juge en premier et dernier ressort → ex : La CAA de Paris est seule compétente en matière d'arrêté ministériel relatif à la représentativité territoriale ou les décisions rendues par la Commission nationale d'aménagement commercial pour les autres CAA.

Pour le reste, les CAA sont juge d'appel et leur décisions ne sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation devant le CE.

3) Les juridictions administratives spécialisées

► Notion de juridiction administrative

Deux critères principaux :

- **Nature de l'acte ayant créé l'organisme**: depuis **CoCo 1961 « organisation judiciaire »**, seule la loi crée un ordre de juridiction. **CE Rubin de Servens 1962** : création du tribunal militaire pendant la guerre d'Algérie pour juger les déserteurs, et le CE reconnaît que ce TM est une juridiction
- Critère matériel : nature du litige. Règle définie dans : **CE 1947, D'ailières** : le CE reconnaît que l'organisme a le caractère d'une juridiction par la nature des affaires

Les juridictions spécialisées sont le plus souvent des juridictions qui interviennent en matière disciplinaire pour sanctionner l'auteur de fait dans le cadre d'une répression non pénale, il existe un certain nombre de critères qui permettent d'identifier une juridiction : la composition de l'organisme.

► La diversité des juridictions administratives spécialisées

La Cour des comptes : juge les comptes de toutes les administrations françaises, elle vérifie les erreurs de gestion dans les services publics, elle rend aussi des rapports annuels.

D'autres ont des fonctions de contrôle de gestionnaire des comptes publics sous le contrôle de la Cour des Comptes (ex : la Cour d'appel financière).

Il y a aussi les juridictions disciplinaires (ex : le Conseil supérieur de la magistrature).

Section 2 : Les compétences des juridictions administratives

1) Le critère légal

► La compétence exclusive de la juridiction administrative (3 blocs de compétence)

- **les travaux publics** (responsabilité contractuelle et extra-contractuelle en matière de travaux publics)
Extra-contractuelle : **Arrêt 1921, commune de Montsegur** : le CE estime que les travaux exécutés dans une église pour le compte d'une personne publique sont des travaux publics, et donc les actions dirigées contre les communes à raison des dommages provenant du défaut d'entretien, relèvent de la compétence du JA.
CE 1955 Effimieff : les litiges relatifs à un marché de travaux relèvent de la compétence du JA, compétence élargie des travaux publics aux ouvrages publics.
- **Le domaine public** : **art L2321 CG3P**, sont portés devant le JA tous les recours de domaine public
- **les contrats de la commande publique** : Tous les marchés publics, toutes les concessions de travaux et de service, y compris les délégations de SP sont des contrats administratifs en application de **l'art L6 du code de la commande publique**.

► La compétence du JA dans les contentieux partagés avec le JJ

ex : Contentieux fiscal et financier = repartitions des compétences entre JJ compétent en matière de condition de recouvrement des impôts y compris les impôts directs (absence de paiement) et JA compétent pour connaître des litiges relatifs à l'établissement de l'impôt, aux bases imposables et son bien fondé de l'impôt direct.

2) Le critère organique

► le contrat conclu au moins par une personne publique

- une personne publique : La qualité de signataire d'un contrat par une personne publique **n'est pas un élément suffisant** → **Sté des granites porphyroïde des Vosges 1992** : en l'absence de clause exorbitante de droit commun, il n'appartenait pas au JA d'en connaître. On retient aussi la notion de régime exorbitant ou l'objet du contrat (**CE époux Bertin 1956** ou **CE consort Grimoire 1956**)

- 2 personnes publiques : **TC Union des assurances de Paris (UAP) 1983** : un contrat conclu entre deux personnes publiques devait en principe avoir un caractère administratif.

⚠️ sauf si l'objet du contrat fait naître entre les parties des rapports de droit privé (JJ)

► Le contrat conclu par un mandataire d'une personne publique

CE Société d'équipement de la région Montpellier Rennes 1975 : JA compétent en cas de mandat

TC commune d'Agde 1975 : le mandat peut être explicite mais aussi implicite.

3) les critères matériels retenus par les Juridictions administratives

► Critère de la puissance publique

CC 1987 : définit une réserve des compétences au juge administratif → compétence de la juridiction administrative pour des décisions prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif

→ La compétence du JA est très large à chaque fois qu'une personne publique prend une décision et met en œuvre ces PDPP (y compris pour p. priv)

CE Etablissement Veolia 1935 : Confie au JA le soin de connaître l'acte pris par des p. priv parce que celle-ci exerce des PPP.

► Le critère du service public

CE Blanco 1873 : ce critère justifiait la compétence du JA en matière de responsabilité.

Mais est parfois disputée ou partagée avec le JJ :

- **le SP de la justice** : **TC préfet de la Guyane 1952** : il faut différencier l'organisation (SP est activité administrative donc relève de la compétence du JA) et le fonctionnement (relève de la juridiction judiciaire) de la Justice judiciaire.

- **Le caractère administratif ou industriel ou commercial du service public** :
(voir fiche SPIC SPA S3)

THÈME 3 : LES SOURCES EXTERNES

Le droit Français et admin comprennent de nombreux textes qui proviennent du droit international et européen ce qui a des conséquences sur l'activité administrative. Les AA doivent respecter les sources du droit internes et externes.

1) L'insertion des sources externes dans l'ordre interne

Art 53 C° : énonce plusieurs catégories de traités internationaux qui doivent être ratifiés et approuvés en vertu d'une loi (ne prenne effet qu'à condition d'avoir été ratifié ou approuvé)
Ceux non visés par cet article peuvent être mis en œuvre par un décret.

Art 55 C° : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie => condition de réciprocité

► La ratification et l'approbation = insertion formelle d'un traité international dans l'ordre juridique interne.

- Pour les traités visés à l'article 53 de la Constitution, une loi de ratification est requise (contrôlée uniquement par le Conseil constitutionnel)
- Pour les autres traités, la ratification se fait par décret (contrôlé par le JA).

⚠ Le juge administratif ne contrôle pas la régularité de la loi de ratification ni la compétence du législateur. En revanche, lorsque la ratification est faite par décret, le Conseil d'État est compétent pour :

- vérifier le respect de la procédure réglementaire,
- censurer le décret si l'administration a ratifié un traité qui aurait dû relever de la loi (article 53) **CE 1998 SARL du arc d'activité de Blotzheim**,
- écarter les dispositions couvertes par des réserves françaises.

Le JA peut aussi connaître indirectement des traités via des actes administratifs mettant en œuvre la loi de ratification ou les stipulations du traité.

► La publication

Un traité non publié est inapplicable en droit interne (**CE, 1981, Commune de Thionville**). La publication conditionne son entrée en vigueur en France, même si le traité est déjà en vigueur à l'international. Pour le droit de l'UE :

- Les règlements sont directement applicables à la date qu'ils fixent.
- Les directives nécessitent une transposition (⚠ pendant le délai, l'État doit s'abstenir de toute mesure contraire (**CE, France Nature Environnement, 2001**), et après le délai, en l'absence de transposition, certaines dispositions peuvent produire des effets.)

► La réciprocité

La condition de réciprocité est remplie lorsque tous les États signataires ont ratifié le traité (**CE, 2010, Cheriet-Benseghir**).

Son contrôle est principalement diplomatique, non juridictionnel : le juge renvoie traditionnellement au ministre des Affaires étrangères (**CE, Rekhrou, 1981**).

Initialement, le Conseil d'État refusait de discuter l'interprétation ministérielle, mais cette position est aujourd'hui remise en cause au regard du droit au procès équitable garanti par la CEDH.

2) la primauté des sources externes

L'art 55 de la constitution pose le pp de la supériorité des traités sur la loi nationale.

► l'affirmation du principe de primauté

Les traités internationaux constituent désormais des sources du droit international, ce qui n'était pas le cas sous la IVe République. L'article 26 de la C° dispose que les traités ont force de loi dans le cas où il serait contraire à des lois françaises. Ce qui veut dire que les traités prévalent sur la loi nationale. De plus, le droit international postérieur prime sur la loi antérieure.

? Est ce qu'un acte admin est « légal » par rapport a la loi ou par rapport aux traités ?

Le Ce y répond dans l'Arrêt Dame Kirkoud 1952 : Un acte administratif (même individuel) doit respecter les conventions internationales régulièrement ratifiées.

→ Lorsque le traité postérieur à la loi le traité s'applique car dans certains cas il a fallu une loi pour insérer le traité dans l'ordre interne.

→ Lorsque la loi est plus récente que le traité : ce n'est plus vraiment une q° avec le contrôle de conventionnalité.

La loi antérieure ou postérieure, doit être conforme à la source externe.

Dans la décision IVG de 1975, le Conseil Constit juge qu'il existe en réalité 2 contrôle de constitutionnalité (le CC se déclare incompétent pour le contrôle de conventionnalité) :

- le contrôle de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61 de la C° = contrôle exercé par le CC
- le contrôle de l'inconstitutionnalité d'une loi par rapport a un traité international = compétence des juges ordinaires.

Cour de cass 1975 Société des cafés Jacques Vabres : fait prévaloir le traité sur la loi nationale.

Mais quelques années avant, le CE avait imaginé la « loi écran » pour faire prévaloir quand c'est nécessaire l'application de la loi nationale, en considérant qu'il fallait appliquer a l'acte contesté la loi et que cette loi faisait écran a la loi internationale. Cette position du CE va le conduire a tjr privilégier l'application de la loi jusqu'a ce que cette position deviennent impossible = la loi contrevient au droit communautaire.

Arrêt Nicolo de 1989 : le Conseil d'État accepte enfin de contrôler la conformité des lois aux traités internationaux. (le contrôle de compatibilité est possible parce que la constit permet d'apprécier la portée du contrôle qu'il effectue).

→ Abandon de la théorie de la loi-écran

→ Alignement sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Jacques Vabre, 1975)

► La portée actuelle du principe de primauté

A : Application large du principe

— application matérielle : la portée de l'art 55 dépasse le droit communautaire

CE 1990 « association familiale, catholique et autres » : la primauté s'étend à d'autres traités que les traités communautaires : primauté de la convention euro des droits de l'homme qui prime sur la loi postérieure.

CE 2000 Zaïdi : considère deux hypothèses :

- tous les Etats signataires de l'engagement le plus récent sont assis parti a l'engagement le plus ancien
- il va appliquer d'une part le traité le plus récent des les relations entre les 2 Etats parties au traité, et il va appliquer l'ancien traité entre les autres parties.

— application dans le temps : Le JA estime qu'un traité international s'applique à compter de son entrée en vigueur et n'est rétroactif que si la loi le prévoit.

La recherche du moment où la loi devient inconstitutionnelle est de la compétence du juge. Le JA recherche si l'incompatibilité existait dès l'adoption de la loi (traité antérieur) ou est apparue après (traité postérieur)

→ **Arrêt Meyet** = la loi qui devient incompatible avec un traité doit être écartée.

Le juge n'annule pas la loi, mais refuse de l'appliquer au litige

La légalité de l'acte admin sera apprécié au regard du traité. Il peut arriver aussi que l'incompatibilité de la loi résulte de la manière dont l'administration l'applique, notamment via un décret d'application.

CE, Vasilikiotis : Le juge peut enjoindre à l'administration de prendre des mesures réglementaires dans un délai raisonnable pour se conformer au droit européen

B : Question de l'extention du principe de primauté en droit de l'UE

Le droit de l'Union européenne (UE) a une particularité : il n'est ni totalement du droit international, ni du droit interne classique. C'est une source externe, mais qui a vocation à s'appliquer directement dans l'ordre juridique français.

Cette spécificité se traduit notamment par l'**article 88-1 de la Constitution** : La République participe à l'Union européenne, constituée d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités, d'exercer en commun certaines de leurs compétences. (introduit par **la réforme constitutionnelle du 25 juin 1992**). Son rôle est devenu concret lorsque le Conseil constitutionnel (CC) a contrôlé la constitutionnalité de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (2004). Le CC a affirmé :

- La transposition des directives européennes a désormais une portée constitutionnelle, fondée sur l'article 88-1
- Ce contrôle ne repose plus sur l'article 55 (qui ne concernait que les traités internationaux), mais sur l'article 88-1.

Décision du 19 nov 2004 : le terme « Constitution » du traité n'enlève pas son caractère de traité international, mais consacre l'existence d'un ordre juridique communautaire intégré à l'ordre interne et distinct du droit international classique. La Constitution française reste la norme suprême, ce qui constitue un obstacle à la primauté automatique du droit de l'UE en France.

CC « Jeu d'argent et de hasard en ligne » 2010 : Le contrôle constitutionnel de conformité du droit de l'UE s'effectue désormais sur la base de l'article 88-1.

Il revient au juge ordinaire de vérifier si une loi nationale respecte les engagements européens de la France.

1 : Le droit dérivé de l'UE : règlements et directives

Le droit de l'UE n'est pas seulement constitué des traités (droit primaire) : il comprend aussi des actes normatifs (droit dérivé) adoptés par les institutions européennes.

→ Règlements : obligatoires et directement applicables (**CE, arrêt Boisdet, 1990** : impose la prééminence des règlements européens sur la loi nationale).

→ Directives : fixent des objectifs à atteindre, laissant aux États le choix des moyens et nécessitent une transposition.

2 : L'effet des directives avant et après transposition

→ **Avant l'échéance de transposition** : Si la directive est adoptée par l'UE mais que la France n'a pas encore fait la loi de transposition, le CE (juge administratif) peut quand même appliquer le droit européen. Pour cela, il regarde s'il existe déjà une règle de l'UE ou un principe européen qui permet de protéger les droits visés par la directive.

CE, arrêt Harselor Atlantique, 2007 : l'administration doit appliquer le droit de l'UE même si la directive n'a pas encore été transposée, pour assurer l'effectivité de l'obligation constitutionnelle.

→ **Après transposition tardive ou mauvaise transposition** : Si le délai est dépassé et que la directive n'a pas été correctement transposée dans le droit français, le justiciable peut demander au juge d'écarter la loi nationale ou les règlements qui contredisent la directive.

CE, arrêt Perreux, 2009 : le justiciable peut demander l'annulation d'une disposition nationale incompatible avec les objectifs de la directive, même si la directive n'a pas encore été transposée.

→ **Limites : clause de sauvegarde** : Le juge peut refuser d'appliquer une directive ou un règlement si cela priverait le justiciable d'une garantie constitutionnelle fondamentale.

CE, 17 décembre 2021 et CE, 27 avril 2021, Association French Data Network : le juge peut écarter une directive ou un règlement si son application priverait le justiciable d'une garantie constitutionnelle sans équivalent dans le droit de l'UE.

C : Les obstacles à l'extension du principe de primauté du droit de l'UE

Même si le droit de l'UE prime sur le droit interne, cette primauté n'est pas absolue. Il existe des limites.

1 : Le droit international

Le champ du principe de primauté ne concerne pas l'ensemble du droit international (certains traités, la coutume internationale).

CE, arrêt Aquarone, 1997 → la coutume internationale n'est pas directement applicable aux justiciables en droit interne

CE, arrêt Saleh, 2011 → nuance : si aucune loi interne ne s'applique, la coutume internationale peut être appliquée.

CE, arrêt Kandyrine, 2011 → confirme que l'application des accords internationaux doit se faire en conformité avec la coutume internationale.

Conclusion : la primauté internationale est limitée et dépend du type de norme.

2 : La Constitution et les dispositions d'ordre constitutionnel

La Constitution française reste la norme suprême. Le CE a décidé qu'il pouvait écarter la primauté des textes internationaux ou européens quand ils contredisaient des dispositions d'ordre constitutionnel.

CE, arrêt Koné, 1996 : le CE écarte l'acte d'extradition malgré un engagement international à cause d'un PFRLR (la France n'extrade pas pour motifs politiques).

CE, arrêt Sarrazin, 1998 et Mademoiselle Frayssse 2000 : « la suprématie des engagements internationaux ne s'applique pas aux dispositions de nature constitutionnelle ».

Mais pour la CJUE, même une disposition constitutionnelle nationale ne peut empêcher l'application du droit de l'UE sur le territoire national.

CJCE, Handelsgesellschaft, 1970 → la primauté du droit de l'UE s'impose même face à des normes constitutionnelles nationales.

3) L'invocabilité des sources externes

A :

1 : Conditions liées au contenu :

Tous les traités internationaux ne peuvent pas être invoqués par des particuliers devant le juge administratif.

- les Traités qui régissent uniquement les relations entre États ne créent pas de droits pour les particuliers → Donc pas d'effet direct.
- les Traités qui concernent aussi les personnes physiques ou morales peuvent créer des droits subjectifs. Ces droits peuvent être invoqués devant le juge si certaines conditions sont remplies.
→ effet direct

2 : Conditions liées à la portée de l'acte

Même si un traité concerne les particuliers, ce n'est pas suffisant. Pour qu'il ait effet direct, il faut que les stipulations soient :

- Précises (Elles doivent être claires, sans ambiguïté).
- Inconditionnelles (Elles ne doivent pas dépendre d'une intervention du législateur ou d'un acte complémentaire)

Si la norme nécessite une mesure d'application → pas d'effet direct.

CE, 1997, GISTI Le Conseil d'État affirme qu'une stipulation internationale : ne peut être invoquée par un particulier que si elle crée des droits à son profit Si elle ne produit pas d'effet direct → le juge l'écarte.

CE, 2012, GISTI Le Conseil d'État précise : Il n'est pas compétent pour apprécier les relations entre États. Mais il peut reconnaître l'effet direct d'une stipulation.

B : l'invocabilité des actes dérivés des traités européens

On distingue les règlements et les directives.

→ Les règlements : Le principe est celui de l'applicabilité directe. L'article 288 TFUE prévoit que le règlement : est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout État membre.

Cela signifie qu'il s'intègre automatiquement dans l'ordre juridique interne dès sa publication. Il n'a pas besoin de mesure de transposition.

CE, 1970, Syndicat viticole des Hautes Graves de Bordeaux : Le Conseil d'État reconnaît que le règlement est directement applicable donc directement invocable.

→ Les directives européennes (bcp plus complexe) :

Article 288 TFUE : La directive lie les États membres quant au résultat à atteindre, mais laisse le choix des moyens = Elle nécessite donc une transposition

Contrairement au règlement elle n'est pas directement applicable et n'a pas automatiquement effet direct. (**CE, 1978, Cohn-Bendit** : Une directive ne peut pas être invoquée contre un acte administratif individuel). Mais évolution :

CE Ass., 3 février 1989, Compagnie Alitalia : Le CE juge qu'après expiration du délai de transposition, l'administration ne peut pas laisser subsister des règlements contraires à la directive. Elle ne peut pas adopter des règlements incompatibles

Conséquence : Le juge doit faire produire des effets à la directive. C'est le début du revirement.

CE, 1992, Société Arizona Tobacco Products et CE, 1992, Philip Morris France : le CE juge que le requérant doit pouvoir invoquer une directive non encore transposée pendant le délai de transpositions. La directive est directement invocable. Impose aussi à l'État de respecter ses obligations. L'obligation de transposition est inconditionnelle + si l'état a choisi de ne pas transposer il ne peut pas lui-même invoquer la directive qu'il n'a pas encore transposée. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Arrêt Tête 1998 : le CE montre que la directive doit prévaloir pour ne pas léser les droits de justiciables en raison d'une simple date de transposition choisie par l'État.

CC, 2004, Loi pour la confiance dans l'économie numérique Le Conseil constitutionnel affirme que la transposition d'une directive est une exigence constitutionnelle (fondement : article 88-1 C°). Donc l'obligation de transposition a valeur constitutionnelle (Sauf disposition expresse contraire de la Constitution)

CE Ass., 30 octobre 2009, Mme Perreux Le CE juge que tout justiciable peut se prévaloir de l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive lorsque l'état n'a pas pris pendant les délais impartis les mesures de transpositions.

⚠ Condition : Le délai de transposition doit être expiré et la directive doit être précise et inconditionnelle

Les directives peuvent désormais avoir effet direct vertical.

C : l'interprétation et le dialogue des juges

CE Ass., 29 juin 1990, GISTI : Le Conseil d'État affirme qu'il est compétent pour interpréter lui-même les traités internationaux.

Le droit de l'UE prévoit dès l'origine une procédure spécifique :

Article 267 TFUE : Les juridictions nationales peuvent (et parfois doivent) saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour interpréter les traités, pour interpréter règlements et directives et pour apprécier la validité des actes européens.

CE, 1964, Société des pétroles Shell-Berre : S'il estime que le texte européen est clair, il refuse de poser une question préjudicielle.

Avec le temps, le CE adopte une position beaucoup plus coopérative :

CE, 2006, Société De Groot en Slot Allium BV : Le CE affirme qu'il doit suivre l'interprétation donnée par la CJUE, même si la question n'a pas fait l'objet d'un renvoi dans l'affaire en cause. Toute interprétation de la CJUE s'impose au juge administratif.

TC, 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau : Le Tribunal des conflits affirme que Le juge national : doit assurer le plein effet du droit de l'Union et peut laisser inappliquée de sa propre autorité toute disposition nationale contraire.

Le CEDH : À l'origine il n'existait pas de mécanisme analogue au renvoi préjudiciel dans le système de la CEDH.

Mais Protocole n°16 depuis 2018 qui permet aux juridictions suprêmes nationales de demander un avis consultatif à la Cour européenne des droits de l'homme.

CE, 15 avril 2021, Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs
Le Conseil d'État saisit la CEDH pour avis consultatif.

THEME 4 : SOURCE INTERNES

1) les sources de valeur constitutionnelle

CC, 16 juillet 1971, **Liberté d'association** : Le Conseil constitutionnel reconnaît que la Constitution ne se limite pas à son texte de 1958. Il consacre le bloc de constitutionnalité,.

► La Constitution écrite et le contrôle du JA

CE, 6 novembre 1936, **Arrighi** : Le Conseil d'État affirme qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la conformité d'une loi à la Constitution.

→ Si un acte administratif est pris en application d'une loi, et que cette loi est contestée comme inconstitutionnelle, le juge administratif refuse d'examiner le moyen parce que la loi fait écran entre l'acte administratif et la Constitution. (Théorie de la loi écran).

Cas de l'écran transparent :

CE, 17 mai 1991, **Quintin** : Le Conseil d'État admet que si la loi se contente de renvoyer au pouvoir réglementaire sans fixer elle-même de règles précises alors : la loi ne fait pas réellement écran et le juge peut contrôler directement l'acte administratif au regard de la Constitution.

► la Constitution jurisprudentielle

Article 62 de la Constitution : les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Donc en théorie : Le Conseil d'État doit appliquer la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Mais au départ, le Conseil d'État était réticent à reconnaître pleinement l'autorité du Conseil constitutionnel même si : Même si : CC, 1962, Loi d'orientation agricole = le Conseil constitutionnel affirme que ses décisions ont autorité de chose jugée. Le CE n'en tire pas immédiatement toutes les conséquences.

CE, 20 décembre 1985, **Société des établissements Outters** : Pour la première fois, le Conseil d'État : vise explicitement l'article 62 de la Constitution, reconnaît l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel, et applique directement la jurisprudence constitutionnelle.

→ Le CE accepte pleinement l'autorité du CC.

CE, 1994, **SA La Cinq** : Le Conseil d'État cite explicitement les décisions du Conseil constitutionnel pour fonder sa solution.

Les PFRLR : Les PFRLR (Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République) sont des principes dégagés par le Conseil constitutionnel. Le CE va progressivement reprendre ces principes, et les appliquer lui-même.

CE, 1996, **Koné** : Le Conseil d'État découvre lui-même un PFRLR : Le principe selon lequel l'État doit refuser l'extradition lorsqu'elle est demandée dans un but politique.

2) les sources de valeur législatives

► Les ordonnances et la loi

1 : les ordonnances

Art 38 C° : Le Parlement peut habiliter le Gouvernement à intervenir dans le domaine de la loi pour une durée limitée par ordonnances

Avant ratification l'ordonnance a valeur réglementaire et peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le CE.

Une fois ratifiée par le Parlement elle acquiert valeur législative et devient insusceptible de recours devant le juge administratif (CE, 2018, Conseil national de l'ordre des infirmiers).

La ratification a un effet rétroactif : l'ordonnance est réputée législative depuis son entrée en vigueur.

CC, 28 mai 2020, Association Force 5 : Le Conseil constitutionnel admet qu'une ordonnance ratifiée peut être contestée par QPC.

2 : la loi

CC, 16 décembre 1999, Codification par ordonnance : Le Conseil constitutionnel reconnaît que l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi sont des objectifs à valeur constitutionnelle (OVC).

→ Le législateur doit adopter des normes claires.

→ Le juge doit interpréter la loi à la lumière de cet objectif.

Le juge administratif applique toute la loi quelle que soit sa matière (civil, pénal, consommation, concurrence...). Il n'y a pas de cloisonnement.

- CE, 1996, Société Lambda : le CE reconnaît que les dispositions du code pénal peuvent servir de référence pour contrôler la légalité d'un acte administratif.

- CE, 1999, Société EDA (Aéroports de Paris) : Le CE applique les règles protectrices aux usagers d'un service public (code de la consommation).

- CE, 1997, Société Million et Marais : Le CE juge qu'une décision administrative ne doit pas méconnaître les règles de concurrence, ne doit pas créer ou renforcer une position dominante abusive. L'administration doit prendre en compte le droit de la concurrence.

► Les pp généraux du droit

Les PGD sont des principes non écrits, dégagés par le juge administratif, applicables même sans texte. L'objectif est d'éviter le déni de justice et de permettre le contrôle de l'administration en l'absence de loi. Ce sont des principes non écrits, dégagés par le juge, applicables même en l'absence de texte. Ils peuvent être inspirés par le droit constitutionnel, les lois, le droit international) mais ce sont des principes autonomes.

Ils ont une valeur au minimum supra-réglementaire (ils permettent d'annuler un règlement). Ils s'imposent à l'administration mais la loi peut y déroger sauf si le pp a valeur constitutionnelle.

CE, 1936, Demoiselle Bobard : Le CE consacre le principe d'égal accès des femmes et des hommes aux emplois publics, alors qu'aucun texte général ne le prévoyait (pas de mention explicite des PGD)

→ préfiguration du pp d'égalité

CE, 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier : le CE consacre les droits de la défense.

→ Naissance d'un PGD applicable même sans texte

CE, 1945, Aramu : Première utilisation explicite de l'expression « principes généraux du droit » (protection du droit de la défense).

→ Les PGD sont applicables même sans texte et ont une valeur supra-décretale

CE, 1950, **Dehaene** : reconnaît le droit de grève des agents publics (PGD)

CE, 1951, **Société des concerts du conservatoire** : Consécration du principe d'égalité des usagers du service public.

CE, 1959, **Syndicat général des ingénieurs-conseils** : Le CE affirme que les PGD s'imposent à toute autorité réglementaire, même en l'absence de texte.

→ Les PGD ont valeur législative.

→ Ils sont supra-réglementaires, même dans le domaine de l'article 37 donc tout règlement peut être censuré pour violation d'un PGD.

Après la décision du Conseil constitutionnel **Liberté d'association (1971)**, apparition du bloc de constitutionnalité. Le CE distingue désormais :

- PGD à valeur réglementaire. Ex : droit d'exercer un recours hiérarchique
- PGD classiques (valeur législative) Supérieurs aux règlements. La loi peut y déroger
- Principes à valeur constitutionnelle : Le législateur ne peut y déroger. Ex : principe d'égalité (CE, 1978, **GISTI** : Le CE distingue principes constitutionnels et PGD ordinaires.)

Les PGD peuvent s'inspirer du droit international (ex : Affaire « José Maria » (réfugié) :

Le CE s'inspire de la Convention de Genève pour dégager un principe protecteur en matière d'extradition).

Le CE a développé des PGD plus spécialisés (PGD « techniques ») :

CE, 2002, **Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle** : obligation pour l'employeur public de reclasser un agent physiquement inapte, ou, à défaut, de le licencier.

CE, 1973, **Dame Peynet** : Interdiction de licencier une femme enceinte (même sans texte). Depuis repris par le Code du travail.

3) Les autres sources de la légalité

Le juge administratif (JA) a adopté une démarche progressive et proactive : Il ne contrôle pas seulement les actes administratifs classiques (décrets, arrêtés...), mais aussi certains documents émis par l'administration, soit parce qu'ils peuvent faire l'objet d'un recours, soit parce qu'ils peuvent servir de norme de référence pour contrôler d'autres actes.

⚠ Les actes de droit privé ne constituent pas des sources de la légalité administrative

► L'invocabilité variable des contrats administratifs

Les contrats administratifs occupent une place particulière.

Ils sont conclus par une personne publique, soumis au juge administratif et susceptibles de recours.

Mais leur invocabilité comme norme de légalité varie selon le type de recours.

Depuis l'évolution du contentieux contractuel, le juge administratif peut être saisi comme juge de plein contentieux.

- Il peut contrôler la validité du contrat.
- Il peut annuler, résilier ou indemniser.

Mais cela concerne le contentieux contractuel, pas le recours pour excès de pouvoir. Le REP est un recours objectif dirigé contre un acte administratif unilatéral.

CE, 1988, **Ministre du Plan c/ Communauté urbaine de Strasbourg** : La méconnaissance des stipulations d'un contrat ne peut pas être utilement invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir.

En effet, Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Il ne constitue pas une norme générale supérieure. Il ne peut donc pas servir de norme de référence objective dans un REP.

► L'admission du droit souple

À côté des règlements et des décisions individuelles, l'administration a développé des instruments de droit souple.

Ces instruments semblent parfois échapper aux catégories classiques du droit administratif.

Ces actes ne peuvent pas échapper au contrôle, sous peine de déni de justice mais ils ne doivent pas être interdits, car ils permettent souplesse, adaptabilité et efficacité de l'action administrative.

Le droit souple regroupe des instruments comme les avis, les recommandations, les chartes, les codes de déontologie...

Exemple : chartes universitaires, recommandations d'autorités administratives indépendantes, messages du CSA.

Ces actes sont souvent unilatéraux, non impératifs en apparence, mais susceptibles d'influencer fortement les comportements.

CE, 2016, Fairvesta International GmbH et autres et CE, 2016, Numericable (Arrêts rendus le même jour) : Le Conseil d'État opère un revirement majeur. Il accepte que certains actes de droit souple puissent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir mais pose des conditions :

Le recours est recevable si l'acte :

- est de nature à produire des effets notables,

OU

- a pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles il s'adresse.

→ Tous les actes de droit souple ne sont donc pas attaquables. Seuls ceux remplissant ces critères peuvent être contestés.

ex : Le juge a admis qu'une mise au point relative à un message publicitaire diffusé à la télévision pouvait faire l'objet d'un recours. Les prises de position publiques d'autorités administratives indépendantes peuvent donc être contrôlées si elles influencent significativement les comportements.

ex : Les lignes directrices (anciennement appelées « directives »). Elles définissent des orientations générales que l'administration entend suivre.

Avant 2016, elles n'étaient pas attaquables directement.

Après Fairvesta : Elles peuvent être attaquées si elles produisent des effets notables.

CE, 2020, GISTI

Le Conseil généralise la solution : Les documents de portée générale émanant de l'administration sont susceptibles de recours s'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes, ou d'influer significativement sur les comportements.

Cet arrêt étend la logique de 2016 à l'ensemble des documents administratifs de portée générale.

THÈME 5 : LE RESPECT DE L'ÉTAT DE DROIT PAR L'ADMINISTRATION

Idée générale :

Question centrale : l'administration a-t-elle tout pouvoir pour imposer des décisions aux administrés ?

Le droit administratif est inégalitaire : l'administration dispose de prérogatives de puissance publique.

Mais dans un État de droit, ces pouvoirs sont limités et encadrés par le droit.

Le Conseil d'État a progressivement légitimé sa compétence pour contrôler l'administration et renforcé les droits des administrés, notamment par les principes généraux du droit (PGD).

L'administration doit donc respecter le droit et engage sa responsabilité en cas d'illégalité.

L'État de droit implique donc un encadrement juridique de l'action administrative et la possibilité pour tout administré de saisir un juge.

Le contrôle du juge dépend de la marge de manœuvre laissée à l'administration par les textes :

- Le pouvoir discrétionnaire : Lorsque la règle de droit laisse une large liberté d'action à l'administration.
→ Le juge exerce alors un contrôle restreint. Il sanctionne seulement : l'erreur manifeste d'appréciation.
- La compétence liée : Lorsque les textes imposent une décision déterminée à l'administration.
→ L'administration n'a aucune marge d'appréciation et le juge exerce un contrôle approfondi.

Tous les actes administratifs ne sont pas contrôlables.

Pour être attaquant, un acte doit :

- constituer une décision
- produire des effets juridiques
- arrêter une position définitive

Principe du recours pour excès de pouvoir :

CE, Dame Lamotte : Le recours pour excès de pouvoir est ouvert même sans texte contre tout acte administratif produisant des effets juridiques.

Certains actes échappent au contrôle du JA :

- les actes de gouvernements
- les mesures d'ordre intérieur

1) Les actes de gouvernement

Les actes de gouvernement sont des actes du pouvoir exécutif insusceptibles de recours devant le juge administratif. Le juge a créé cette catégorie pour éviter de s'immiscer dans les affaires politiques du gouvernement.

Initialement, pour reconnaître un AG, on retenait le mobile politique (**CE Laffitte**), mais ce critère a été abandonné dans l'arrêt **CE Prince Napoléon**.

→ Premier domaine : **les relations entre les pouvoirs publics constitutionnels** (ex : le recours aux pleins pouvoirs Arrêt **Rubin de Servens**, la dissolution de l'AN...).

→ Deuxième domaine : **la conduite des relations internationales**

La jurisprudence a progressivement réduit cette catégorie en reconnaissant la détachabilité de certains actes.

ex : le refus d'extradition d'un étranger peut être contrôlé par le JA (**CE, Gouverneur de la colonie royale de Hong Kong**)

2) Les mesures d'ordre intérieur (MOI)

Les mesures d'ordre intérieur (MOI) sont des actes pris quotidiennement par l'administration pour organiser le fonctionnement interne des services publics. Elles sont considérées comme trop peu importantes pour justifier l'intervention du juge administratif.

→ les recours dirigés contre ces mesures sont irrecevables.

Cependant, la jurisprudence a progressivement réduit le champ des MOI, en considérant que certaines mesures font grief et doivent donc pouvoir être contestées.

► Les mesures d'ordre intérieur en milieu pénitentiaire

À l'origine, les mesures dans les établissements pénitenciers ne faisaient pas grief (**Arrêt Caillol**). Mais **Arrêt Marie 1995** marque un tournant : la mise en cellule disciplinaire constitue une sanction faisant grief, donc attaquant. La décision fait grief si elle modifie substantiellement la situation de l'intéressée (gravité des effets sur la situation de l'intéressé).

⚠ **CE, Garde des Sceaux c. Frérot** : un détenu refuse une fouille corporelle et est placé en cellule disciplinaire pour maintenir l'ordre dans l'établissement. Dans ce cas, la mesure ne constitue pas une décision faisant grief.

► Les mesures d'ordre intérieur dans les services militaires

CE Hardouin : une punition disciplinaire (punition d'arrêt) infligée à un militaire fait grief (évolution)

► Les mesures d'ordre intérieur dans les écoles et universités

Certaines mesures d'organisation scolaire restent des MOI, mais la jurisprudence a également réduit leur champ.

Ex : **CAA Versailles** : une décision de séparer des jumeaux de 4 ans est susceptible de recours, car elle affecte la situation des enfants.

⚠ Liberté d'expression : **CE Kherouaa** : une interdiction générale et absolue est illégale. L'arrêt reconnaît la liberté d'expression des élèves, limitant le pouvoir réglementaire des établissements.

► Les mesures d'organisation concernant les agents publics

Les agents publics sont constamment soumis à des mesures d'organisation du service.

Toutes ne peuvent pas être attaquées, sinon l'action administrative serait paralysée.

Ce n'est pas la nature de la mesure, mais ses effets qui déterminent si elle est attaquant.

Une mesure est attaquant lorsqu'elle :

- porte atteinte aux droits ou libertés de l'agent ;
- porte atteinte aux prérogatives tirées de son statut ;
- entraîne une perte de responsabilité ;
- constitue une mesure discriminatoire ou de harcèlement.

CE, Bourjolly : les changements d'affectation peuvent être contestés lorsqu'ils ont des conséquences sur la situation de l'agent.

Section 3 : Le décalage du standard de la légalité

Dans un État de droit, il peut exister plusieurs niveaux de légalité selon les circonstances : l'administration reste toujours soumise au droit, mais dans des situations exceptionnelles, elle peut prendre des mesures qu'elle ne pourrait pas adopter en temps normal.

⚠ Ce décalage doit être :

- provisoire
- temporaire
- localisé
- proportionné aux circonstances

→ L'administration ne peut pas agir au-delà des nouvelles limites de la légalité.

► Les pouvoirs exceptionnels de l'article 16 de la Constitution

L'article 16 de la Constitution permet au Président de la République d'exercer des pouvoirs exceptionnels. Conditions :

- menace grave et immédiate sur les institutions de la République, l'indépendance de la Nation ou l'intégrité du territoire
- interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels

CE, Rubin de Servens

Principe : la décision de mettre en œuvre l'article 16 constitue un acte de gouvernement (donc insusceptible de recours). Cependant les mesures prises pendant l'article 16 peuvent être contrôlées selon leur nature. Si la mesure relève du domaine législatif, elle a valeur législative et le JA n'est pas compétent

► L'état de siège

L'état de siège correspond à une situation militaire exceptionnelle.

Il peut être déclaré par décret en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée.

Durée : 12 jours maximum, sauf prolongation par le Parlement.

Il a pour conséquences le transfert de certains pouvoirs de l'autorité civile à l'autorité militaire.

Cependant, l'État de droit demeure applicable.

L'article L.2121-8 du Code de la défense prévoit que les droits garantis par la Constitution continuent de s'exercer sauf suspension prévue par la loi.

CE, Delmotte : fermeture des débits de boissons pendant l'état de siège peut être justifiée par les circonstances exceptionnelles.

► L'état d'urgence

Contrairement à l'état de siège, les pouvoirs ne sont pas transférés à l'armée. les mesures restent entre les mains des autorités civiles.

Cet état d'urgence permet une action plus rapide et plus large pour maintenir l'ordre public.

loi du 3 avril 1955 : il doit durer 12 jours, puis prolongation par loi votée par le Parlement.

Conditions de déclenchement

L'état d'urgence peut être déclaré en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou en cas de calamité publique.

Les autorités administratives peuvent notamment :

- interdire la circulation des personnes et véhicules ;
- interdire le séjour d'une personne dans un département ;
- assigner à résidence ;
- dissoudre des associations ou groupes menaçant gravement l'ordre public.

⚠ Toutes ces mesures sont contrôlées par le juge administratif.

CE, **Franpar** : le Conseil d'État annule la mesure car la saisie était justifiée par des motifs politiques et non par l'ordre public.

▶ La théorie des circonstances exceptionnelles

Même sans texte spécifique, l'administration peut parfois prendre des mesures qui seraient illégales en temps normal → circonstances exceptionnelles (ex : guerre, catastrophe majeure).

Ces circonstances permettent : d'assouplir les règles de légalité mais toujours sous le contrôle du juge administratif.

Première jurisprudence

CE, **Heyriès** : pendant la guerre, l'administration peut déroger à certaines règles de procédure.

CE, **Dame Dol et Laurent**

Le juge reconnaît que les circonstances exceptionnelles peuvent justifier des restrictions plus fortes aux libertés.

⚠ Même en cas de circonstances exceptionnelles, les mesures doivent rester proportionnées. Elles ne peuvent pas porter une atteinte excessive aux libertés fondamentales.

Une interruption totale et indéterminée d'une liberté, comme la liberté d'expression, serait illégale.

THÈME 6 : Les contentieux de l'administration

Principe : Les administrés disposent du droit d'exercer un recours contre l'administration.

Ce droit est garanti par plusieurs normes :

- Conseil constitutionnel : le droit au recours effectif est un principe constitutionnel, rattaché à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
- Convention européenne des droits de l'homme :
 - article 13 : droit à un recours effectif ;
 - article 6 §1 : droit à un procès équitable.

Principe posé par l'article 6 : toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement publiquement, dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

L'administré peut saisir les juridictions administratives ordinaires ou les juridictions administratives spécialisées. Mais l'accès au juge administratif est très formalisé. Le droit administratif repose sur une théorie des recours contentieux.

Les demandes doivent entrer dans une catégorie précise de recours. Sinon la demande peut être sans objet ou irrecevable.

1) La distinction des recours contentieux

► La distinction en fonction des pouvoirs du juge

Les membres du Conseil d'État ont élaboré au XIX^e siècle une classification des recours. Ils ont identifié quatre branches du contentieux administratif selon les pouvoirs du juge.

Le juge peut exercer :

- un pouvoir d'indemnisation
- un pouvoir d'interprétation
- un pouvoir d'annulation
- un pouvoir de réformation
- un pouvoir de répression

Ces pouvoirs ont conduit à distinguer :

- le contentieux de pleine juridiction
- le contentieux de l'annulation
- le contentieux de l'interprétation ou de la déclaration
- le contentieux de la répression

A. Le contentieux de pleine juridiction

C'est le contentieux dans lequel le juge dispose des pouvoirs les plus étendus.

Il peut statuer : sur des questions de droit objectif et sur les questions de droits subjectifs.

Le juge peut notamment condamner l'administration à indemniser, modifier une décision administrative ou encore substituer sa décision à celle de l'administration. Il faut en principe un texte prévoyant la compétence du juge de plein contentieux sinon l'annulation relève du recours pour excès de pouvoir.

Principales matières relevant du plein contentieux : responsabilité administrative, contentieux contractuel, contentieux fiscal, contentieux du droit d'asile

→ Ces matières impliquent souvent des droits subjectifs.

B. Le contentieux de l'annulation

Dans ce contentieux, les pouvoirs du juge sont plus limités. Lorsqu'il est saisi, le juge peut seulement : rejeter la requête ou annuler la décision administrative.

Il existe deux recours principaux.

1. Le recours pour excès de pouvoir

C'est le recours dirigé contre tout acte administratif illégal.

CE, Dame Lamotte : Le recours pour excès de pouvoir est ouvert même sans texte contre tout acte administratif. Ce recours constitue une garantie essentielle de la légalité administrative.

2. Le déféré préfectoral

Le préfet peut saisir le juge administratif pour contester les actes des collectivités territoriales. Ce mécanisme participe au contrôle de légalité des actes locaux.

Évolution : Le recours pour excès de pouvoir est devenu de plus en plus largement recevable.

C. Le contentieux de l'interprétation ou contentieux de la déclaration

Dans ce contentieux, les pouvoirs du juge sont plus limités.

Le juge peut interpréter un acte administratif et apprécier sa légalité mais il ne peut pas l'annuler.

1. Les questions préjudicielles

Le juge administratif peut être saisi par le juge judiciaire pour interpréter un acte administratif apprécier sa légalité. Le juge administratif rend alors une décision d'interprétation ou de validité.

2. L'exception d'illégalité

L'exception d'illégalité est une voie de droit incidente.

Elle permet de contester la légalité d'un acte administratif supérieur à l'occasion d'un recours dirigé contre un autre acte.

Le juge ne peut pas annuler que l'acte attaqué au principal mais il peut déclarer illégal l'acte supérieur. Conséquence : l'acte supérieur n'est pas annulé mais son illégalité entraîne celle de l'acte attaqué.

CE, Compagnie Alitalia : l'administration doit abroger sans délai un règlement illégal.

3 : Le recours en déclaration de droits

Créé par une loi de 2016 (l'article L.77-12-1 du Code de justice administrative).

Ce recours permet à une association ou à un syndicat de demander au juge la reconnaissance de droits individuels résultant d'un texte au profit d'un groupe indéterminé de personnes.

Le recours peut notamment viser le versement d'une somme d'argent légalement due ou la décharge d'une somme indûment réclamée.

D : Le contentieux de la répression

Dans ce contentieux, le juge administratif exerce un pouvoir de sanction. Il peut infliger des amendes. Il agit alors comme un juge pénal administratif.

Ce contentieux concerne les atteintes au domaine public immobilier. Il s'agit d'infractions consistant à porter atteinte matériellement au domaine public ou aux ouvrages publics. (ex : pollution d'un canal, dégradation d'un ouvrage public, occupation illégale du domaine public).

Le juge administratif organise la répression de ces infractions.

⚠ Exception : les infractions relatives à la voirie routière relèvent du juge judiciaire.

► Distinction selon la situation juridique invoquée

On distingue le contentieux objectif et le contentieux subjectif.

1. Le contentieux objectif

Le juge est saisi d'une question de droit objectif : il vérifie la légalité d'un acte administratif.

Deux types de rapports :

- rapport de conformité : l'acte doit être strictement conforme à la norme supérieure (pas de marge d'appréciation).
- rapport de compatibilité : l'acte doit seulement ne pas contredire la norme supérieure (marge d'appréciation pour l'administration).

Contentieux objectifs principaux :

- recours pour excès de pouvoir (CE Dame Lamotte)
- contentieux de l'appréciation de légalité
- contentieux électoral
- contentieux des édifices menaçant ruine
- contentieux de la répression

2. Le contentieux subjectif

Le juge protège un droit subjectif du requérant.

Exemples :

responsabilité administrative

contentieux contractuel

contentieux fiscal

indemnisation

2 : La remise en cause de la distinction entre contentieux de l'excès de pouvoir et plein contentieux

Traditionnellement, le droit administratif distingue :

- le contentieux de l'excès de pouvoir (REP) : le requérant demande l'annulation d'un acte administratif.
- le contentieux de pleine juridiction : le juge peut modifier la décision, condamner l'administration ou accorder une indemnisation.

Dans le recours pour excès de pouvoir, seuls des moyens de légalité peuvent être invoqués. Le juge ne peut pas être saisi de simples moyens de fait.

→ Le requérant doit démontrer juridiquement l'illégalité de l'acte administratif.

La distinction s'atténue progressivement.

► La remise en cause liée à l'office du juge

Depuis une vingtaine d'années, le juge administratif refuse de rester enfermé dans la rigidité de la distinction entre REP et plein contentieux. Plusieurs raisons expliquent cette évolution :

- les litiges présentent souvent à la fois une dimension objective et subjective
- les requérants formulent des demandes plus complexes que la simple annulation d'un acte

Le risque d'irrecevabilité

La théorie des recours impose au requérant de demander exactement ce qui correspond au recours utilisé.

Exemple : dans un recours pour excès de pouvoir, le requérant ne peut normalement demander que l'annulation de l'acte. Sinon, le recours peut être irrecevable.
Pour rendre les recours plus utiles, le juge administratif accepte parfois qu'une demande d'annulation soit accompagnée d'une demande indemnitaire accessoire.

CE, Société La Foncière des Champs-Élysées : une demande d'indemnisation accessoire à une demande d'annulation ne transforme pas le recours pour excès de pouvoir en plein contentieux.

CE, Marcou : la nature du recours dépend à la fois des conclusions du requérant et des moyens invoqués. Si les moyens sont exclusivement des moyens de légalité, le recours reste un recours pour excès de pouvoir.

La réparation d'un préjudice peut donc dépendre de l'illégalité de la décision administrative. Or cette illégalité est établie par les moyens soulevés dans le recours pour excès de pouvoir. Ainsi l'office du juge de l'excès de pouvoir et celui du juge de plein contentieux se rapprochent.

► L'extension des pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir

Le juge administratif s'est également intéressé à l'exécution des décisions d'annulation. Traditionnellement, le juge de l'excès de pouvoir devait seulement rejeter le recours ou annuler l'acte administratif

CE, Rodière : un acte annulé pour excès de pouvoir est réputé n'avoir jamais existé.

Conséquence : l'administration doit tirer toutes les conséquences de l'annulation.

Le juge administratif a progressivement développé des solutions intermédiaires entre le rejet du recours et l'annulation immédiate.

Obligation d'agir dans un délai raisonnable

CE, Vassilikiotis : le juge impose à l'administration de prendre une décision dans un délai raisonnable sinon la décision sera annulée.

Technique du délai d'abrogation

CE, Titran : le juge peut laisser un délai à l'administration pour abroger une décision illégale. si l'administration n'agit pas dans ce délai → annulation de l'acte

3) Le contentieux des mesures provisoires

Le juge administratif est traditionnellement un juge du fond : ses décisions règlent définitivement les litiges. Cependant, certaines situations nécessitent une intervention rapide du juge avant le jugement au fond.

→ D'où l'existence d'un contentieux des mesures provisoires, permettant d'obtenir une réponse rapide mais temporaire. (En droit privé, ce rôle est assuré depuis longtemps par le juge des référés.)

En droit administratif, cette possibilité s'est développée avec la loi du 30 juin 2000, qui a profondément réformé les référés administratifs. Cette loi permet au juge de répondre à l'urgence sans trancher définitivement le litige sans préjuger de la décision au fond.

Selon l'article L.511-1 du Code de justice administrative, les référés sont des mesures provisoires.

► Les référés soumis à la condition d'urgence

Ces référés ne peuvent être exercés qu'en présence d'une situation d'urgence. La loi ne définit pas précisément l'urgence, c'est donc le juge administratif qui en a précisé la notion. Trois référés principaux sont concernés : le référé suspension, le référé liberté, le référé mesures utiles.

1. L'urgence en référé suspension

La définition de l'urgence a été donnée par :

CE, Confédération nationale des radios libres : L'urgence existe lorsque la décision administrative contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate :

- à un intérêt public
- à la situation du requérant
- ou aux intérêts qu'il entend défendre.

Cette définition n'est pas purement temporelle, elle implique une appréciation concrète de la situation.

2. L'appréciation concrète de l'urgence

Le juge examine l'ensemble des circonstances de l'affaire.

CE, Préfet des Alpes-Maritimes et Société Sud-Est Assainissement : le requérant doit justifier concrètement l'urgence, que le juge apprécie au regard de toutes les circonstances de l'espèce.

Le juge effectue donc une balance des intérêts en présence.

3. Les présomptions d'urgence

Dans certaines situations, le juge reconnaît plus facilement l'urgence.

Exemples : suppression d'une rémunération, refus de restitution d'un permis de conduire pour un professionnel de la route

→ Ces situations créent une présomption d'urgence.

4. Le référé liberté

Le référé liberté protège les libertés fondamentales. Conditions :

- atteinte grave
- atteinte manifestement illégale
- urgence extrême

Le juge doit statuer dans les 48 heures.

Le Conseil d'État définit l'urgence comme la nécessité pour le requérant de bénéficier à très court terme de la mesure demandée.

5. Le référé mesures utiles

Dans ce référé, le juge peut ordonner toute mesure utile pour protéger les droits du requérant.

Condition importante : la mesure ne doit pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

L'urgence est appréciée plus largement : elle existe lorsque la mesure demandée est nécessaire pour protéger les droits du requérant.

A : Le référé suspension

Le référé suspension permet de faire obstacle au caractère non suspensif des recours contentieux en suspendant l'exécution d'une décision administrative dans l'attente du jugement au fond.

Conditions

1 : Un recours au fond préalable

→ Nécessité d'un recours pour excès de pouvoir, ou d'un recours de plein contentieux. Le référé ne peut pas être introduit seul

Exception : possible en cas de recours administratif préalable obligatoire (RAPO)

2 : L'urgence

→ Atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant

3. Un doute sérieux sur la légalité

→ Existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision

Procédure

- Procédure orale et contradictoire
- Moyens et pièces peuvent être présentés jusqu'à l'audience
- Instruction close à l'issue de l'audience

Décision du juge

- Juge des référés statuant en principe seul
- Rend une ordonnance
- Mesure provisoire sans autorité de la chose jugée

Évolution des mesures

Possibilité de :

- modifier les mesures
- mettre fin à la suspension
- introduire une nouvelle demande en cas d'éléments nouveaux

Exemple : Refus initial de suspension d'un permis de construire, puis nouvelle demande lorsque les travaux commencent

Finalité = Assurer un contrôle provisoire de l'exécution de la décision administrative pendant l'instance au fond

B : Le référé liberté (art. L.521-2 CJA)

Le référé liberté permet au juge d'ordonner toute mesure nécessaire pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en situation d'extrême urgence.

⚠ Particularité : Il peut être exercé sans décision administrative formelle et contre des agissements ou abstentions de l'administration

Conditions :

1 : Une atteinte grave et manifestement illégale

- Illégalité évidente portant sur une liberté fondamentale

2 : Une liberté fondamentale

- Depuis CE, 2001, Commune de Venelles : Toutes les libertés fondamentales sont invocables, y compris constitutionnelles

Exemples : liberté d'aller et venir, liberté de réunion, droit de propriété, liberté contractuelle, liberté administration des collectivités territoriales

3 : Une extrême urgence

- Nécessité d'une intervention immédiate

Délai : le juge statue dans les 48 heures

Procédure

- Procédure très rapide
- Contrôle strict des conditions par le juge

Évolution jurisprudentielle

Loi du 30 juin 2000

TC, 2013, Bergoend : réduction de la voie de fait et renforcement du rôle du référé liberté

Efficacité

Recours fréquent

Taux de succès faible (conditions strictes)

Finalité = Assurer une protection immédiate et effective des libertés fondamentales

► Les référés en matière contractuelle

Les référés contractuels concernent exclusivement les contrats de la commande publique :

- marchés publics
- concessions (dont délégations de service public)

Ils ont pour objet de garantir le respect des règles de publicité et de mise en concurrence lors de la passation des contrats.

⚠ Important :

- Ils ne peuvent être exercés qu'au stade de la passation
- Ils sont irrecevables pendant l'exécution du contrat → pendant l'exécution, seuls les référés de droit commun sont possibles (référé suspension, provision, mesures utiles).

A : Le référé précontractuel

Le référé précontractuel est un recours créé sous l'influence du droit de l'Union européenne et codifié à l'article L.551-1 du Code de justice administrative. Il permet de sanctionner les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence avant la signature du contrat.

Il ne peut être exercé que tant que le contrat n'est pas signé. Une fois la signature intervenue, le recours devient irrecevable.

Son effet principal est de suspendre la procédure de passation. L'introduction du recours empêche donc la signature du contrat jusqu'à la décision du juge.

Le recours doit être exercé dans un délai de 11 jours à compter de la notification du rejet de l'offre. La recevabilité est appréciée largement, puisqu'il suffit que le requérant ait été susceptible d'être lésé.

Les moyens invocables sont variés et concernent toutes les irrégularités de la procédure : documents de consultation, critères de sélection, déroulement de la procédure ou motifs d'éviction.

Le juge dispose de pouvoirs très étendus. Il peut annuler tout ou partie de la procédure, enjoindre sa reprise à un stade précis, neutraliser des critères ou suspendre la passation.

Ce recours est très utilisé et constitue une contrainte importante pour les acheteurs publics.

B : Le référé contractuel

Le référé contractuel a été créé en 2009. Il permet de contester un contrat après sa signature, lorsqu'un référé précontractuel n'a pas pu être exercé.

Il s'agit d'un recours subsidiaire. Le requérant doit démontrer qu'il aurait pu former un référé précontractuel mais qu'il en a été empêché, notamment en raison d'un défaut d'information sur la procédure.

Ce recours concerne par exemple les entreprises qui n'ont pas eu connaissance du marché et n'ont donc pas pu candidater, alors même qu'elles auraient eu un intérêt à le faire.

En pratique, ce référé est peu fréquent, car l'intérêt à agir est difficile à établir et les situations permettant son exercice sont limitées.

► Les autres référés

A : Le référé constat et le référé instruction

Ce référé permet d'obtenir la désignation d'un expert, principalement en matière de travaux publics.

L'expert a pour mission de constater l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, ainsi que d'en déterminer les causes et l'étendue.

Ce référé est peu utilisé en pratique, car son champ est limité et il est concurrencé par le référé mesures utiles, plus souple.

B) Le référé provision

Le référé provision permet au requérant d'obtenir du juge des référés le versement d'une somme d'argent à titre d'avance sur une indemnisation.

En pratique, cette provision correspond souvent à la totalité de l'indemnisation, ce qui en fait une alternative rapide au recours au fond. Le juge statue généralement dans un délai de quelques mois, alors qu'un recours au fond est beaucoup plus long.

Ce référé est soumis à une condition essentielle : l'obligation invoquée ne doit pas être sérieusement contestable. Cela signifie qu'il ne doit pas exister de doute sérieux sur le droit à indemnisation, notamment sur le plan juridique.

Il est en outre nécessaire que le requérant ait préalablement adressé une demande indemnitaire à l'administration.

C) Le référé fiscal

Le référé fiscal concerne les impôts directs et les taxes sur le chiffre d'affaires. Il est exercé par le contribuable lorsque l'administration refuse les garanties qu'il propose pour obtenir un sursis de paiement. Il permet ainsi au contribuable d'éviter de payer immédiatement l'impôt contesté, malgré le refus initial de l'administration.

D) Le référé audiovisuel

Ce référé est mis en œuvre uniquement par le président de l'ARCOM. Il permet de saisir le Conseil d'État afin d'obtenir une ordonnance imposant aux chaînes de télévision de respecter leurs obligations légales et conventionnelles.

Ces obligations résultent notamment des conventions conclues entre les chaînes privées et l'ARCOM. Ce référé peut conduire à des mesures importantes, comme l'interdiction de diffusion d'une chaîne en cas de manquements graves.

E) Informatique et libertés

Il existe deux référés spécifiques en la matière.

Le premier permet d'obtenir qu'une personne publique mette fin à une atteinte aux règles relatives à la protection des données personnelles, notamment en cas de violation du RGPD ou de la loi Informatique et libertés.

Le second permet au requérant d'obtenir la communication de ses données personnelles. Ce référé peut également être exercé devant le juge judiciaire.

4) Le contentieux de l'exécution

► Exécution et autorité de la chose jugée

Les décisions du juge administratif sont, par principe, exécutoires. Elles s'imposent à l'administration en vertu de l'autorité de la chose jugée.

Cette autorité est reconnue de longue date par la jurisprudence. Dans l'arrêt CE, 1904, Botta, le Conseil d'État affirme que les décisions juridictionnelles doivent être respectées.

Dans l'arrêt CE, 1925, Rodière, il précise que les décisions rendues en excès de pouvoir sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée. Cela signifie qu'elles s'imposent à tous. En revanche, dans les autres contentieux, les décisions ne bénéficient que d'une autorité relative, limitée aux parties au litige. La différence tient surtout à l'intensité de l'effet et non à sa nature.

Cependant, malgré ce principe, il n'existait jusqu'en 1995 aucun mécanisme permettant de contraindre effectivement l'administration à exécuter les décisions de justice. L'autorité de la chose jugée reposait donc essentiellement sur une obligation théorique, sans garantie réelle d'exécution.

► L'exécution des jugements administratifs

En droit administratif, l'exécution des décisions de justice ne peut pas passer par les voies d'exécution du droit privé. En effet, les biens des personnes publiques sont insaisissables, comme l'a affirmé la Cour de cassation dans l'arrêt Civ. 1re, 1987, BRGM.

Il en résulte que, pendant longtemps, l'exécution des décisions reposait essentiellement sur la bonne volonté de l'administration.

Pour remédier à cette situation, le législateur est intervenu :

La loi du 16 juillet 1980 a introduit un pouvoir d'injonction au profit du Conseil d'État, avec possibilité d'astreinte, mais son usage est resté limité.

La loi du 8 février 1995 a généralisé ces pouvoirs à toutes les juridictions administratives, assurant une meilleure effectivité des décisions de justice.

1: Les injonctions a priori

Prévues aux articles L.911-1 et L.911-2 du Code de justice administrative, elles sont prononcées directement dans la décision du juge.

L'article L.911-1 s'applique lorsque l'exécution implique nécessairement une décision dans un sens déterminé. Le juge impose alors une solution précise, généralement favorable au requérant.

L'article L.911-2 vise les cas où l'administration doit seulement réexaminer la situation. Le juge impose une nouvelle instruction, sans garantir le sens de la décision finale.

Dans les deux cas, le juge peut fixer un délai et assortir l'injonction d'une astreinte, c'est-à-dire une somme due par jour de retard. Cette astreinte vise à contraindre l'administration à exécuter la décision.

2 : Les injonctions a posteriori

Elles interviennent lorsque l'administration n'a pas exécuté une décision de justice.

Le justiciable saisit alors le juge de l'exécution. Une phase administrative s'ouvre d'abord, durant laquelle l'administration est invitée à expliquer son inaction. Si l'inexécution persiste, le juge peut prononcer une injonction d'exécuter, éventuellement assortie d'une astreinte.

Thème 7 – Le recours pour excès de pouvoir (REP)

Le recours pour excès de pouvoir occupe une place centrale en droit administratif. Il s'agit d'un recours en annulation dirigé contre un acte administratif unilatéral.

Dans l'arrêt CE, 1950, Dame Lamotte, le Conseil d'État affirme qu'il s'agit d'un recours ouvert même sans texte contre tout acte administratif, afin d'assurer le respect de la légalité conformément à un principe général du droit.

L'annulation prononcée a un effet rétroactif : selon l'arrêt CE, 1925, Rodière, l'acte annulé est réputé n'être jamais intervenu.

Les caractères du REP :

1) Un procès fait à un acte

Selon Laferrière, le REP est dirigé contre un acte et non contre une personne.

Il s'agit toutefois d'une fiction, car le requérant agit toujours dans son intérêt. Le juge vérifie d'ailleurs l'existence d'un intérêt à agir, condition de recevabilité du recours. En pratique, il existe donc bien un enjeu pour le requérant.

2) Un recours d'utilité publique

Le REP vise à faire respecter la légalité administrative, ce qui lui confère une dimension d'intérêt général. C'est pour cette raison qu'il est ouvert même sans texte. Toutefois, cette idée connaît une limite importante : le requérant doit justifier d'un intérêt personnel pour agir.

3) Un recours d'ordre public

Le REP tend à assurer le respect de la légalité, ce qui relève de l'ordre public.

Le juge peut prononcer une annulation totale, définitive et rétroactive de l'acte. Cette annulation s'impose à tous : les décisions rendues en REP sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée.

Il n'est donc pas possible de renoncer aux effets d'une annulation prononcée par le juge.

1) Les conditions de recevabilité du REP

Les conditions de recevabilité correspondent au contrôle préalable effectué par le juge pour vérifier si le recours peut être examiné.

Elles consistent en des exigences formelles imposées au requérant, qui varient selon le type de recours. Elles sont particulièrement importantes car un recours irrecevable n'est pas examiné au fond. Ainsi, le rejet pour irrecevabilité ne signifie pas que l'acte est légal ou illégal, mais seulement que le juge ne peut pas se prononcer.

Il existe plusieurs conditions de recevabilité, dont le respect du délai de recours.

► Le respect du délai de recours

Le recours doit être exercé dans un délai de deux mois :

- à compter de la publication pour les actes réglementaires
- à compter de la notification pour les actes individuels

À l'expiration de ce délai, le recours est tardif et donc irrecevable. On parle de forclusion.

Ce délai est un délai d'ordre public. Il ne peut pas être écarté, sauf si un texte prévoit un délai différent.

Le délai est un délai franc :

il commence à courir le lendemain de la publication ou de la notification

s'il expire un jour non ouvrable, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant

► Un recours contre une décision faisant grief

Pour être recevable, le recours pour excès de pouvoir (REP) doit viser un acte qui fait grief, c'est-à-dire qui produit des effets juridiques concrets.

A) Les actes unilatéraux

L'acte doit avoir des effets sur l'ordonnancement juridique ou directement sur le requérant.

L'intérêt à agir du requérant dépend de ces effets : sans effet personnel ou réel, le recours est irrecevable.

Le critère principal n'est pas l'appellation juridique de l'acte, mais ses effets réels sur le requérant.

Seules les décisions produisant un impact concret sur le requérant peuvent être attaquées.

B) Les contrats

En matière de contrats administratifs, le contentieux relève principalement du plein contentieux. Cela signifie que c'est en principe le juge du contrat qui est compétent, notamment pour les référés précontractuels et contractuels.

Toutefois, le juge administratif a admis, à titre exceptionnel, que le recours pour excès de pouvoir (REP) puisse être exercé dans certaines hypothèses, soit contre certaines clauses du contrat, soit contre des actes détachables du contrat. Il en résulte que la compétence du juge de l'excès de pouvoir en matière contractuelle est résiduelle et limitée.

a) La recevabilité du REP à l'encontre d'un contrat

Le principe en matière contractuelle est celui de l'irrecevabilité du REP contre les contrats. Ce principe a été affirmé de manière ancienne par le Conseil d'État dans l'arrêt Martin de 1905, puis confirmé notamment par l'arrêt Compagnie luxembourgeoise de télévision de 1996. Par conséquent, seul le juge du contrat, dans le cadre du plein contentieux, est normalement compétent.

Cependant, ce principe connaît des exceptions.

1) Le REP contre les clauses réglementaires du contrat

Le recours pour excès de pouvoir est recevable uniquement à l'encontre des clauses réglementaires d'un contrat. Il convient de distinguer ces clauses des stipulations contractuelles classiques, qui relèvent du plein contentieux.

Les stipulations contractuelles traduisent en effet la volonté des parties et relèvent d'une logique de consentement, proche de celle du droit privé. À l'inverse, les clauses réglementaires ont pour objet d'organiser le fonctionnement d'un service public ou d'en fixer les conditions d'exploitation.

Par exemple, les clauses tarifaires d'un service public sont souvent fixées unilatéralement par une délibération préalable d'une collectivité territoriale. Les parties ne peuvent pas les négocier, ce qui justifie qu'elles puissent être contestées par la voie du REP.

Le Conseil d'État a reconnu cette possibilité dans l'arrêt Cayzeele de 1996, en admettant le recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires des contrats.

2) Le REP contre les contrats de recrutement d'agents publics

Dans cette hypothèse, ce n'est pas une clause particulière qui est attaquée, mais le contrat dans son ensemble.

Le Conseil d'État a admis cette possibilité car les agents concernés sont des agents contractuels, dont la situation se rapproche de celle des fonctionnaires. Dès lors, leur recrutement peut faire l'objet d'un contrôle par le juge de l'excès de pouvoir.

Dans l'arrêt Ville de Lisieux de 1998, le Conseil d'État a ainsi admis la recevabilité du REP formé par un conseiller municipal contre un contrat de recrutement d'un agent public.

3) Le déféré préfectoral contre les contrats

Le préfet dispose d'une voie de droit spécifique appelée déféré préfectoral, dans le cadre de sa mission de contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales, prévue par l'article 72 de la Constitution.

Ce recours présente deux particularités importantes. D'une part, le préfet n'a pas à justifier d'un intérêt à agir, celui-ci étant présumé en raison de sa mission constitutionnelle. D'autre part, il peut agir soit de sa propre initiative, soit à la demande d'administrés qui ne sont pas en mesure d'exercer eux-mêmes un recours. Le refus du préfet d'exercer ce déféré peut lui-même être contesté.

Dans l'arrêt Commune de Sainte-Marie de 1991, le Conseil d'État a admis la recevabilité du déféré préfectoral contre tout acte d'une collectivité territoriale, y compris les contrats.

b) La recevabilité du REP à l'encontre des actes détachables d'un contrat

Les actes détachables sont des actes distincts du contrat, mais en lien avec celui-ci. Il s'agit d'actes unilatéraux qui peuvent, à ce titre, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Cette solution a été consacrée dès l'arrêt Martin de 1905, qui a ouvert la possibilité pour les tiers d'attaquer ces actes.

Un acte est dit détachable lorsqu'il est soit antérieur à la conclusion du contrat, soit postérieur à celui-ci, mais qu'il ne constitue pas une mesure d'exécution directe du contrat. En revanche, un acte qui participe directement à l'exécution contractuelle est considéré comme non détachable, ce qui rend le REP irrecevable.

1) Les actes préalables

Les actes préalables sont ceux qui participent à la formation du contrat.

Il peut s'agir, par exemple, d'une délibération décidant du mode de gestion d'un service public, de la décision de lancer un marché public, de la composition de la commission d'appel d'offres ou encore de la sélection des candidats.

Ces actes sont tous antérieurs à la signature du contrat et peuvent faire l'objet d'un REP, y compris de la part de tiers.

L'annulation de ces actes peut avoir des conséquences variables sur le contrat. Dans certains cas, elle est sans incidence, par exemple lorsque l'acte concerne la composition de la commission d'appel d'offres ou le rejet d'un candidat. En revanche, lorsque l'acte est essentiel, comme la définition des besoins, son illégalité peut entraîner la nullité du contrat.

Toutefois, le juge de l'excès de pouvoir ne peut pas lui-même prononcer l'annulation du contrat. Il se limite à constater l'illégalité, ce qui oblige ensuite les parties à tirer les conséquences de cette situation, soit en reconnaissant la nullité du contrat, soit en saisissant le juge du contrat.

2) Les actes postérieurs au contrat

Les actes postérieurs sont ceux qui interviennent au cours de l'exécution, de la modification ou de la fin du contrat.

Les parties au contrat ne peuvent pas contester ces actes par la voie du REP. Elles doivent obligatoirement saisir le juge du contrat. Il existe toutefois une exception lorsque l'acte présente un caractère réglementaire, par exemple en matière de tarification d'un service public.

En revanche, les tiers peuvent exercer un REP contre ces actes détachables postérieurs.

Dans tous les cas, l'annulation d'un acte détachable postérieur n'entraîne jamais l'annulation du contrat lui-même.

► Les conditions liées à la qualité du requérant

Pour que le recours pour excès de pouvoir soit recevable, le requérant doit remplir deux conditions : avoir la capacité à agir et justifier d'un intérêt à agir.

1) La capacité à agir

La capacité à agir correspond à la capacité juridique en droit civil. Le requérant doit donc être une personne majeure et ne pas être privée de ses droits civils. Par exemple, une personne sous tutelle ne peut pas agir seule en justice.

Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, celle-ci doit exister juridiquement et être représentée par une personne habilitée. Pour les personnes morales de droit privé, cette habilitation est prévue par les statuts. Pour les personnes publiques, comme les communes, le maire doit être autorisé à agir en justice par une délibération du conseil municipal.

Cette habilitation devient caduque à la fin du mandat. En cas de renouvellement du conseil municipal, une nouvelle délibération est nécessaire, faute de quoi la requête peut être déclarée irrecevable.

2) L'intérêt à agir

Le requérant doit justifier d'un intérêt à agir, apprécié de manière assez large en matière de REP. Cet intérêt doit être direct, personnel, certain, et actuel. Il ne peut pas être simplement éventuel ou futur.

L'intérêt à agir s'apprécie en fonction de la décision attaquée. Il est plus facilement reconnu contre un acte réglementaire que contre un acte individuel, pour lequel il faut être directement concerné.

L'absence d'intérêt à agir entraîne l'irrecevabilité du recours.

3) Les principales hypothèses reconnues par la jurisprudence

Le juge administratif a reconnu plusieurs cas dans lesquels l'intérêt à agir est admis.

D'abord, la qualité de contribuable permet de contester les décisions financières d'une collectivité, comme l'a admis le Conseil d'État dans l'arrêt Casanova de 1901.

Ensuite, les élus peuvent contester les décisions de la personne publique dont ils font partie. Dans l'arrêt Commune de Nérès-les-Bains de 1902, le Conseil d'État a admis le recours d'un maire contre un acte préfectoral.

Le juge reconnaît également un intérêt à agir aux usagers d'un service public contre les actes relatifs à son organisation ou à son fonctionnement, depuis l'arrêt Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli de 1906.

Les personnes sinistrées ou les riverains peuvent aussi agir lorsqu'une décision affecte directement leur situation.

4) Le cas des personnes morales

Les personnes publiques ne peuvent agir que dans le cadre de leurs compétences. Dans l'arrêt Préfet de l'Eure de 1913, le Conseil d'État a jugé qu'une autorité administrative ne peut pas demander au juge d'exercer un pouvoir qu'elle détient déjà. Toutefois, dans l'arrêt Commune de Grande-Synthe de 2020, il a reconnu un intérêt à agir d'une commune fondé sur des considérations climatiques.

Les personnes morales de droit privé, comme les syndicats ou associations, ne peuvent agir que pour défendre les intérêts collectifs de leurs membres. Dans l'arrêt Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges de 1906, le Conseil d'État a précisé qu'elles ne peuvent pas contester des décisions purement

► Les conditions liées à l'absence d'un recours parallèle

Le choix du recours dépend en principe des conclusions du requérant, qui déterminent la branche du contentieux applicable. Toutefois, dans certains cas, le juge administratif a encadré ce choix afin d'éviter que le requérant contourne les règles de compétence entre les différents types de contentieux.

C'est notamment le cas en présence de décisions à caractère pécuniaire, qui présentent une particularité : elles soulèvent à la fois une question de légalité et une question financière, puisque le requérant cherche souvent à obtenir une somme d'argent ou à être déchargé d'une obligation de paiement.

Dans l'arrêt Lafage de 1912, le Conseil d'État a précisé la règle applicable. En l'espèce, il s'agissait du refus d'un avantage pécuniaire à un militaire. Le juge a considéré que, lorsque le requérant se borne à contester la légalité d'une décision ayant un objet exclusivement pécuniaire, le litige relève du recours pour excès de pouvoir.

Cette solution s'applique notamment au contentieux des oppositions à titre de recette (hors matière fiscale). Par exemple, lorsqu'une administration émet un titre de recette, le recours dirigé contre cette décision relève en principe du REP si le requérant conteste uniquement sa légalité.

En revanche, lorsque le litige ne porte pas exclusivement sur une question de légalité, mais comporte une demande de réparation ou d'indemnisation, il relève du plein contentieux.

Toutefois, lorsque la demande indemnitaire est fondée uniquement sur une illégalité de l'administration, le juge de l'excès de pouvoir peut être compétent pour apprécier cette illégalité.

2) Les cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir

Les cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir (REP) correspondent aux motifs juridiques permettant de contester la légalité d'un acte administratif. Autrement dit, ils répondent à la question de savoir dans quels cas et pour quelles raisons un REP peut être exercé.

Le REP est un recours d'ordre public et très largement ouvert. Toutefois, il ne peut être exercé efficacement que si le requérant invoque des arguments juridiques précis, correspondant à des cas d'ouverture reconnus.

Le Conseil d'État a progressivement développé ces cas d'ouverture, ce qui a permis d'élargir les possibilités offertes aux requérants. Plus les cas d'ouverture sont nombreux, plus il est facile de démontrer l'illégalité d'un acte administratif. C'est ainsi que le REP est devenu un recours de droit commun contre les actes administratifs.

1) Les deux grandes causes juridiques

Les cas d'ouverture sont aujourd'hui classés selon deux grandes causes juridiques qui correspondent aux deux types d'illégalité pouvant affecter un acte administratif :

a) La légalité externe

La légalité externe regroupe tout ce qui concerne :

la compétence de l'auteur de l'acte

la procédure d'adoption de l'acte

Elle vise donc tous les éléments extérieurs à l'acte lui-même, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles il a été pris.

b) La légalité interne

La légalité interne concerne le contenu de l'acte, c'est-à-dire :

ses motifs

son objet

ses effets

Elle renvoie à ce qui est intrinsèque à la décision administrative.

Chacune de ces deux causes juridiques se divise en deux cas d'ouverture, ce qui structure l'ensemble du contentieux de l'excès de pouvoir.

2) L'invocation des cas d'ouverture : la règle de l'arrêt Intercopie

Les cas d'ouverture peuvent être invoqués par le requérant, mais leur utilisation est encadrée dans le temps.

Pendant le délai de recours contentieux (en principe deux mois), le requérant peut invoquer librement des moyens relevant :

de la légalité externe

et de la légalité interne

En revanche, après l'expiration de ce délai, la situation est figée.

Dans l'arrêt Société Intercopie de 1953, le Conseil d'État a posé la règle suivante :

→ après l'expiration du délai de recours, le requérant ne peut plus invoquer un moyen relevant d'une cause juridique différente de celle déjà invoquée dans sa requête initiale.

Autrement dit, si le requérant n'a soulevé que des moyens de légalité interne dans le délai, il ne pourra plus, après ce délai, invoquer des moyens de légalité externe, et inversement.

Cette règle peut avoir des conséquences importantes. En effet, un moyen potentiellement décisif peut être jugé irrecevable s'il n'a pas été soulevé dans le délai de recours.

3) Intérêt de la classification

La distinction entre légalité externe et légalité interne permet d'organiser les moyens de manière claire et rationnelle.

Elle guide le requérant dans la construction de son argumentation et permet au juge administratif d'exercer un contrôle structuré de la légalité des actes administratifs.

► Les moyens de la légalité externe

Les moyens de légalité externe concernent toutes les irrégularités liées à l'auteur de l'acte ou à sa procédure d'adoption. Ils regroupent principalement l'incompétence et les vices de forme ou de procédure.

A) L'incompétence

L'incompétence est le moyen le plus ancien, reconnu dès 1807. Elle sanctionne le fait qu'une autorité administrative prenne une décision en dehors de ses attributions.

Ce moyen est particulièrement important, car il constitue un moyen d'ordre public. Cela signifie qu'il peut être soulevé à tout moment de la procédure, même après l'expiration du délai de recours et même si aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué initialement. Il échappe ainsi à la règle posée par l'arrêt Société Intercopie de 1953.

L'incompétence peut prendre plusieurs formes.

1) L'incompétence juridique

Il s'agit de l'hypothèse la plus grave, appelée usurpation de pouvoir ou de fonction. Elle se produit lorsqu'une autorité intervient dans un domaine qui relève normalement d'une autre autorité administrative.

2) L'incompétence matérielle

L'incompétence matérielle regroupe plusieurs situations.

D'abord, il peut s'agir d'une *incompétence territoriale*, lorsque l'autorité agit en dehors de son ressort géographique.

Ensuite, il peut s'agir d'une *incompétence ratione temporis*, lorsque l'autorité n'est pas compétente au moment où elle agit, par exemple parce que son mandat est expiré ou qu'elle n'a pas encore reçu les délégations nécessaires.

Enfin, il peut s'agir d'une *incompétence matérielle au sens strict*, lorsque l'autorité intervient dans une matière qui ne relève pas de ses compétences.

Dans tous les cas, l'acte pris par une autorité incompétente est illégal et doit être annulé par le juge administratif.

B) Les vices de forme et de procédure

L'administration est tenue de respecter un certain nombre de règles formelles et procédurales lors de l'adoption de ses décisions.

Le vice de forme concerne la présentation extérieure de l'acte (signature, date, identification de l'auteur). Le vice de procédure concerne le déroulement de la procédure ayant conduit à la décision (consultations, avis, respect du contradictoire).

Certaines règles sont générales : toute décision administrative doit être signée, datée et permettre d'identifier son auteur. D'autres règles dépendent de procédures spécifiques, comme l'obligation de consulter un organisme.

Ainsi, l'absence de consultation d'un organisme obligatoire, une composition irrégulière de celui-ci ou un défaut de quorum peuvent entacher la décision d'illégalité.

1) La distinction entre formalités substantielles et accessoires

La jurisprudence distingue entre :

les formalités substantielles, dont la violation entraîne l'annulation de l'acte

les formalités accessoires, dont la violation est sans incidence

Les formalités substantielles incluent notamment :

- * le respect des droits de la défense
- * le respect du principe du contradictoire
- * l'obligation de motivation des décisions défavorables
- * certaines consultations obligatoires

2) L'apport de l'arrêt Danthony (CE, 23 décembre 2011).

Dans l'arrêt Danthony de 2011, le Conseil d'État a précisé que tous les vices de procédure n'entraînent pas automatiquement l'annulation de l'acte.

Désormais, un vice n'entraîne l'illégalité que dans deux cas :

s'il a privé l'administré d'une garantie

ou s'il a exercé une influence sur le sens de la décision

Par exemple, l'absence de respect des droits de la défense prive l'administré d'une garantie. De même, l'absence de quorum dans une commission peut influencer le sens de l'avis rendu et donc de la décision finale.

3) L'exception d'illégalité et ses limites

Lorsqu'une décision est prise sur la base d'un avis ou d'un acte préalable illégal, le requérant peut soulever une exception d'illégalité à l'encontre de cet acte.

Cependant, le Conseil d'État a limité cette possibilité dans l'arrêt CFDT Finances de 2018. Il a jugé que les vices de forme et de procédure ne peuvent plus être invoqués par voie d'exception contre un acte réglementaire après l'expiration du délai de recours contentieux.

► Les moyens d'illégalité interne

Les moyens de légalité interne concernent le contenu même de l'acte administratif, c'est-à-dire ses motifs, son objet et ses effets. Ils comprennent principalement le détournement de pouvoir et la violation de la loi.

A) Le détournement de pouvoir

Le détournement de pouvoir est un cas d'ouverture rare, car il est difficile à prouver. Il est constitué lorsque l'administration utilise ses pouvoirs dans un but différent de celui pour lequel ils lui ont été confiés.

Ce moyen a été consacré par le Conseil d'État dans l'arrêt Pariset de 1875. Dans cette affaire, le préfet avait ordonné la fermeture d'une fabrique d'allumettes en utilisant ses pouvoirs de police des établissements insalubres, alors que la décision poursuivait en réalité un autre objectif. Le juge a donc sanctionné un usage détourné du pouvoir.

Le détournement de pouvoir peut prendre plusieurs formes.

D'abord, il peut s'agir de l'utilisation d'un pouvoir dans un intérêt personnel. Dans l'arrêt Fabrègues de 1909, un maire avait sanctionné un agent par esprit de vengeance et non dans l'intérêt du service, ce qui caractérise un détournement de pouvoir.

Ensuite, il peut s'agir de l'utilisation d'un pouvoir dans un intérêt général différent de celui prévu par la loi. Par exemple, une autorité peut utiliser un pouvoir de police dans un but financier ou pour favoriser une personne. Dans l'arrêt Gilli de 2015, le Conseil d'État a ainsi sanctionné une décision prise pour favoriser un candidat à un poste universitaire.

3) Les pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir

Le juge de l'excès de pouvoir (JP Rodières, 1925) ne tranche qu'une question de légalité, sans entrer dans les choix de politique publique (LDH, 2023). Traditionnellement, il ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision, mais il a développé des pouvoirs permettant de sauver certaines décisions lorsqu'une annulation serait disproportionnée ou inutile.

► Les pouvoirs liés à l'examen des motifs

Pour neutraliser une décision sans l'annuler entièrement, le juge peut agir sur les motifs de la décision attaquée :

Tri des motifs :

Si un motif déterminant est illégal → annulation

Si le motif est surabondant (illégal mais non déterminant) → il est écarté, la décision peut être maintenue

Substitution des motifs illégaux :

Le juge vérifie que l'administration aurait pris la même décision sur un motif légal.

Si oui → le motif illégal est remplacé, la décision est validée

Substitution de la base légale :

Le juge peut remplacer la base légale erronée par celle qui aurait dû fonder la décision, pour garantir le respect des droits de l'administré.

Peut être fait d'office ou à la demande des parties.

Ces techniques permettent au juge de moduler son contrôle, en sanctionnant l'illégalité sans provoquer l'annulation systématique.

► Les pouvoirs dans le prononcé du dispositif

Le juge peut aussi agir sur l'effet de l'annulation :

Annulation différée dans le temps :

Arrêt Association AC, 2004 : l'annulation peut être limitée dans le temps si une annulation immédiate serait excessive ou préjudiciable.

Le juge doit recueillir les observations des parties avant de décider.

Cas d'assouplissement :

Arrêt Vassilikiotis : le juge peut sanctionner l'illégalité tout en laissant le temps à l'administration de purger la décision.

Ces pouvoirs permettent au juge de concilier respect de la légalité et préservation de l'efficacité administrative, tout en évitant des conséquences disproportionnées pour les administrés.

Thème 8 : La responsabilité pour faute de l'administration

La responsabilité de l'administration ne diffère pas totalement du droit privé, mais elle pose des questions spécifiques. Il faut déterminer quand c'est l'administration elle-même qui est responsable et quand c'est l'agent. L'agent, en tant que personne physique, peut voir sa responsabilité engagée selon le droit commun.

Deux principes fondamentaux structurent le droit administratif : le principe de légalité, qui impose à l'administration de respecter la loi, et le principe de responsabilité, selon lequel l'administration doit rendre des comptes. Historiquement, depuis la Révolution, l'administration a été protégée du contrôle des juges judiciaires et les agents ne pouvaient être poursuivis que devant le Conseil d'État. L'article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen affirme que la société peut demander compte à tout agent public, mais la mise en œuvre de cette responsabilité reste limitée.

Au XIX^e siècle, l'administration était en grande partie irresponsable, sauf pour certains cas comme les dommages liés aux travaux publics. L'arrêt Rothschild (1865) a affirmé que l'administration pouvait être responsable selon des règles particulières. Cette idée a été précisée par l'arrêt Blanco (TC, 8 février 1873), qui établit que la responsabilité de l'État pour les dommages causés par ses agents dans le service public n'est pas régie par le droit civil, mais par des règles spécifiques adaptées aux besoins du service et à la protection des droits des particuliers.

La responsabilité administrative vise avant tout à réparer les dommages et repose sur plusieurs fondements et conditions : la faute, le risque, la rupture d'égalité devant les charges publiques, ou des situations particulières comme l'accident médical.

1) La faute de l'administration et de son agent

► la distinction faute personnelle et faute de service

L'engagement de la responsabilité de l'administration repose sur une distinction essentielle entre faute personnelle et faute de service. La victime d'un dommage peut choisir de poursuivre l'agent ou l'administration, mais ce choix n'entraîne pas automatiquement la responsabilité de celui poursuivi. En pratique, on attaque souvent l'administration, car elle est solvable, contrairement à l'agent.

Si le dommage résulte d'une faute de service, c'est le juge administratif qui est compétent. Si la faute est personnelle mais détachable du service, l'agent peut être poursuivi devant le juge judiciaire. L'arrêt Époux Lemonier (1918) a affirmé que la victime peut saisir l'administration même si le dommage vient d'une faute personnelle de l'agent, introduisant une attraction du contentieux vers le juge administratif.

La distinction entre faute de service et faute personnelle a été précisée par le TC Pelletier (1973), qui rappelle que le juge judiciaire ne peut pas statuer sur les fautes de service, et par Lemonier Carriol (1877), qui définit la faute personnelle comme révélant les imprudences et passions de l'agent. Certaines infractions pénales ou accidents involontaires peuvent être rattachés au service : c'est le cas de l'arrêt Thépaz (TC, 1935). À l'inverse, des comportements très graves en dehors du service, comme dans l'arrêt Papon (CE, 2002), sont considérés comme des fautes personnelles détachables.

Le Conseil d'État a créé la notion de faute non dépourvue de tout lien avec le service pour élargir le champ de la faute de service. La faute de service est le fondement principal de la responsabilité de l'administration : elle est administrative, jugée par le juge administratif, anonyme, fonctionnelle et peut prendre plusieurs formes.